

1516408-55.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/03/2022
... e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico -Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha - Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516408-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1516408-55.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VANDERLEI DOS SANTOS SIQUEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Vanderlei dos Santos Siqueira e Vinicius dos Santos Siqueira, qualificados nos autos nas fls. 22 e 25, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 07/julho/2021, por volta das 06h30, em período de calamidade pública, na Travessa Barreira Branca, 88, Jardim Filhos da Terra, nesta comarca, tinham em depósito, para fins de tráfico, 78g de cocaína, fracionadas em 186 porções e 1.521,9g de tetrahydrocannabinol, substância vulgarmente conhecida como maconha, divididas em 159 porções e 1 tijolo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 1.400,00 em espécie, além de três aparelhos celulares.

Consta na denúncia que, nas circunstâncias descritas, policiais civis, durante operação denominada "Network", diligenciaram ao local dos fatos com o intuito de cumprirem mandado de busca e apreensão, cujo alvo era Vinicius; ao chegarem, tiveram a entrada retardada, devido a presença de dois cães bravos soltos por um morador, tempo suficiente para que Vinicius pulasse o muro e empreendesse fuga com uma bolsa pelas vielas da comunidade, conseguindo escapar da ação dos policiais; em busca no interior do imóvel, foi encontrado Vanderlei e localizadas as citadas drogas, os celulares e a quantia em dinheiro; informalmente Vanderlei confessou que seu irmão Vinicius traficava entorpecentes; diante de tal cenário, Vanderlei foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, onde foi formalmente interrogado e negou a prática delitiva.

A denúncia (fls. 115/117) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/111), sendo a peça acusatória recebida em 16/setembro/2021 (fls. 146/147). Após a necessária notificação/citação, os réus apresentaram suas Defesas Preliminares (fls. 164/167 e 206/209).

Durante a instrução foram ouvidas cinco testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e os denunciados interrogados ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia para ambos os réus, bem como o aumento da pena em razão da grande quantidade da droga, inclusive afastamento da agravante relativa a calamidade pública, bem como não aplicação do redutor relativo ao §4º., do artigo 33; a Defesa do réu Vinicius pediu a absolvição por falta de provas; a Defesa do réu Vanderlei pugnou pelo reconhecimento da confissão do réu, primariedade, antecedentes, aplicação do redutor do §4º, bem como aplicação mínima da pena com substituição por restritiva de direitos.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 16/20; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 178/181 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está nas fls. 12/13.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. O réu Vinicius dos Santos Siqueira, 25 anos, contou que, ao ouvir a polícia chegando na sua casa ficou desesperado; tinha aceitado dinheiro para guardar algumas coisas na residência; soltou os cachorros e tentou fugir; não sabia o que havia nas sacolas; a polícia apareceu antes que a pessoa fosse buscar; ficou sabendo depois que era droga; seu irmão estava dormindo e nada sabia sobre as drogas; receberia a quantia de R\$ 1.000,00; não desconfiou que fosse algo ilegal; mesmo sem saber o que havia na sacola, soltou os cachorros e fugiu da polícia; desconhece se havia dinheiro além das drogas dentro da sacola (áudio sistema SAJ). Interrogado em Juízo, o acusado Vanderlei dos Santos Siqueira, 23 anos, negou a acusação; estava dormindo quando ouviu gritaria no quintal; viu que eram pessoas e o cachorro latindo; viu seu irmão passar correndo com uma sacola na mão, pulando o muro; drogas lhe foram apresentadas e o réu preso; a droga estava na sacola que seu irmão carregava e passou correndo com ela; desconhecia a existência das drogas; não sabia que seu irmão alugava o espaço para guardar a sacola de outra pessoa (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

O depoente Hedlei Medeiros, policial civil, contou que, ao cumprir mandado de busca e apreensão contra Vinicius; no local, chamou pelos moradores; os cães vieram e não permitiram o ingresso na residência; uma pessoa saiu de dentro da casa carregando uma mala de viagem, jogando a bolsa e pulando para a casa ao lado; foi atrás dessa pessoa que pulou com a bolsa, mas não o encontrou; dentro do imóvel encontrou droga (cocaína, maconha etc) espalhada por toda casa, celular, dinheiro; Vanderlei estava dentro da casa e disse que tudo que estava lá pertencia ao irmão Vinicius que havia fugido; Vanderlei não ofereceu residência e permitiu o ingresso na casa; (áudio sistema SAJ).

Sandro Rogério de Oliveira, guarda civil municipal, disse que deu apoio a operação

da polícia civil no dia dos fatos; foram cumprir mandados naquela rua; ao chegar no local, o réu estava detido; fez a varredura com os cães; as drogas já tinham sido encontradas (áudio sistema SAJ).

A testemunha Elói Martins Neto, policial civil, explicou que, ao cumprir mandado de busca e apreensão, foi até o endereço, momento em que alguns cachorros foram soltos; ao tentar entrar, viu alguém pulando o muro, fugindo em seguida; dentro do imóvel encontrou outra pessoa e drogas espalhadas pelo chão, dentro do armário etc; a pessoa presa dentro da casa assumiu que era irmão do traficante que fugiu; Vanderlei disse saber que o irmão era o traficante; o local era chamado de "casa bomba", tratando-se do local onde a droga ficava armazenada (áudio sistema SAJ). A testemunha Mateus da Silva trouxe informações sobre os réus, em especial Vanderlei, amigo de escola há mais de 10 anos; ouviu comentários no bairro que o traficante seria Vinícius; nunca viu Vanderlei usando drogas (áudio sistema SAJ). A testemunha Pablo Diego Alves Teixeira trouxe informações sobre os antecedentes do réu Vanderlei;

Como se vê, a oitiva das testemunhas presenciais, somadas a confissão do réu Vinícius, além do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pela acusação é parcialmente verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com sua conduta, o réu Vinicius se enquadra em, pelo menos, um verbo do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: ter em depósito.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede em parte.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado Vinicius, de razoável quantidade de substância entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), no Auto de Constatação Prévia (fls. 16/20) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 178/181).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu Vinicius, efetivamente, mantinha em depósito, dentro de sua residência, razoável quantidade de cocaína e maconha.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo mantida em depósito, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado Vinicius em sua residência, instante em que fugiu quando visualizou a presença da polícia.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu Vinicius guardava toda a cocaína e maconha apreendida dentro de sua residência, fato este confirmado por ele em uma carta (fl. 128) e depois ratificado em juízo.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (1.521,9g de maconha e 78g de cocaína), o local (dentro da residência) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais civis, em operação denominada Network, diligenciaram ao local dos fatos para cumprir mandado de busca e apreensão, cujo alvo era Vinicius, sendo que o mesmo fugiu ao notar a presença dos agentes, os quais entraram na moradia e localizaram os entorpecentes).

Aliás, a versão de Vinícius de que desconhecia o conteúdo da sacola cai por terra em razão da conduta por ele praticada com a chegada da polícia: soltou os cachorros

para atrasar o ingresso dos policiais na casa e fugiu levando a sacola contendo drogas.

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos hão de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

TRÁFICO - MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. TRÁFICO - AUTORIA - depoimento de policiais civis confirmando a apreensão de drogas em local indicado pelo réu - validade do depoimento das testemunhas policiais. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade - incomum com a figura de usuário - a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo - ausência de condições financeiras para o réu possuir a droga para consumo pessoal - apreensão de dinheiro - abordagem do réu em conhecido ponto de venda - confissão informal do réu de que estava se dedicando ao comércio ilícito - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. PENA - base no mínimo legal - manutenção ante a inércia ministerial - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - ausentes causas de aumento - redutor reconhecido na fração máxima - manutenção ante a inércia ministerial - substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa. REGIME - aberto - manutenção. (TJSP; Apelação Criminal 0091009-63.2018.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminares - Rejeitadas - A nova redação do artigo 212, do Código de Processo Penal não suprimiu do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas, ainda que subsidiariamente, para o esclarecimento da verdade real - Não houve violação do devido processo legal, pois não era mesmo o caso de absolvição sumária - Testemunhas arroladas fora do prazo legal - Inocorrência de nulidade para apresentação dos memoriais, já que o próprio defensor concordou com a não apresentação na audiência - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido trazendo consigo substância entorpecente para imediata comercialização - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência - Validade - Desclassificação para uso - Não acolhimento - Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil - Pena inalterada - Percentual mantido na segunda fase em razão da agravante da reincidência - Redutor negado por se tratar de réu reincidente - Regime mantido - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum de pena aplicado - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501805-11.2020.8.26.0228; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Justiça Gratuita - Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido trazendo consigo drogas de nefastas consequências para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência - Validade - Desclassificação para uso - Não acolhimento - Circunstâncias do caso concreto

indicadoras do intuito mercantil - Pena inalterada - Redutor negado, mercê da comprovada reincidência - Regime mantido em razão da reincidência e da gravidade da conduta - Inviável, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo improvido.(TJSP; Apelação Criminal 1514762-44.2020.8.26.0228; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recursos da defesa e ministerial - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Confissão - Depoimentos coesos dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante - Validade - Condenação mantida - Penas readequadas - Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime fechado de rigor - Inviável substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500898-97.2019.8.26.0510; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado Vinicius injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa.

Com relação ao denunciado Vanderlei a situação é diferente.

Não há provas nos autos acerca da traficância realizada por ele. Policiais foram ao local com mandado de busca e apreensão e indicação acerca do traficante que lá habitava, ou seja, Vinicius. Seria extremamente temerário condená-lo somente pela localização dos entorpecentes na residência em que morava, sendo que havia um alvo pré-determinado.

Ademais, os policiais responsáveis pelo flagrante disseram que Vanderlei os auxiliou no ingresso à residência, prendendo os cachorros e permitindo que entrassem na casa.

Sendo assim, inaceitável a condenação do réu Vanderlei quando existem provas contraditórias ou insuficientes nos autos, gerando dúvida em relação a sua conduta. Na dúvida, deve-se optar por sua absolvição de acordo com o princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu Vinicius realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se

cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu Vinicius é primário (fls. 200/201).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a grande quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, chegando a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de drogas apreendidas, que certamente atingiriam um grande número de pessoas, com consequências devastadoras à sociedade, providência que encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Colaciono jurisprudência no sentido da possibilidade de exasperação da pena base em virtude da quantidade de drogas:

Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - Recursos defensivos - Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários, da defesa de ALLAN, de redução das penas e de diminuição ou isenção da pena pecuniária em razão da sua precária situação econômica - Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os acusados, no tocante aos dois delitos - Penas-base majoradas em face da grande quantidade de maconha apreendida (3.489,42g) - Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor - O valor estipulado a título de sanção pecuniária, correspondente ao mínimo previsto na lei em vigor, não comporta redução por falta de amparo legal - Prisão cautelar do apelante ODAIR que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500849-35.2018.8.26.0302; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, efetuou a diminuição de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, atento a Súmula 231, do STJ..

Embora praticado durante a Pandemia de Covid-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito. Não há nos autos provas de que o acusado se valeu das facilidades decorrentes da situação enfrentada pelo mundo para o cometimento do crime. É fato que a pandemia não facilitou a prática do delito, tampouco agravou seus efeitos. A traficância ocorre em um mesmo grau, faça chuva ou faça sol, em situações pandêmicas ou não. É um câncer que a sociedade enfrenta, infelizmente, sem expectativa de cura num futuro próximo.

No sentido de afastamento da agravante, colaciono jurisprudência:

Cerceamento de defesa - Inversão da ordem de oitivas - Ausência de formalidade processual - Ampla Defesa plenamente exercida - Ausência de comprovação de prejuízo - Preliminar rejeitada. Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenações mantidas - Recursos não providos. Redução da reprimenda - Segunda fase da dosimetria -

Apelantes não se prevaleceram das fragilidades causadas pela pandemia – Majorantes de calamidade pública afastadas -- Recursos providos para este fim. Confissão espontânea – Súmula 545/STJ – Utilizada para a formação do convencimento – Reconhecida a atenuante – Recurso provido para este fim. Tráfico privilegiado – Possibilidade – Primárias, diminuta quantidade de entorpecente e sem comprovação de envolvimento com o meio ilícito – Redutor aplicado para Larissa e Ingrid – Recursos providos para este fim. Regime aberto e substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos por Larissa e Ingrid – Recursos providos para este fim. Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso de Caio não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500858-92.2020.8.26.0571; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021) (grifo meu)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, I E V, DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESTADUALIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. . MÉRITO: Configurados a materialidade, autoria e dolo do agente no delito insculpido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 40, inciso I, do mesmo diploma legal, o desfecho condenatório é de rigor. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE: Conforme o entendimento firmado no âmbito do STJ, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social; . CONDUTA SOCIAL: A propósito, a circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do CP, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, configurando antecedentes sociais, os quais não se confundem com os seus antecedentes criminais. Ou seja, trata-se do estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, desassociado da noção de antecedentes criminais. De modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio da natureza comportamental; . CONFISSÃO ESPONTÂNEA: O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado; . CALAMIDADE PÚBLICA: Não é suficiente a vigência do Decreto que reconheceu estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do Covid-19, para a incidência da agravante do art. 61, II, 'j', do Código Penal. O agravamento da pena exige a existência de situação concreta dando conta que o réu se prevaleceu da pandemia, que justificou o Decreto, para a prática do tráfico de drogas, situação não verificada no caso concreto; . CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE: Para caracterização da causa de aumento descrita no inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, faz-se necessário comprovar que a droga provém de outro Estado ou que se trata de tráfico entre Estado e Distrito Federal, não bastando simplesmente que o agente transponha ou pretenda transpor os limites de uma ou mais Unidades da Federação, até chegar ao seu destino final. No caso, não é possível averiguar a prática de tráfico entre Estados e, sim, apenas que a droga tinha como destino o Estado de São Paulo ou do Ceará. Mantida apenas a transnacionalidade do delito; . CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO: Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo; . No caso, as circunstâncias dos autos, tomadas em seu conjunto, traduzem indicativos de que o

réu integra grupo criminoso e se dedica à atividade delitativa, de modo que a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não tem lugar como redutor de pena. (TRF4, ACR 5001996-93.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator GUILHERME BELTRAMI, juntado aos autos em 10/03/2021) (grifo meu)

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de ½ (metade), chegando-se a pena final de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras. Entende este juízo que, embora grande a quantidade de droga, não há qualquer outra prova nos autos que o acusado faça parte de organização criminosa ou exerça o ilícito habitualmente, razão pela qual o redutor deve ser aplicado, porém em grau intermediário. Neste sentido:

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela referendo a absolvição e o direito de apelar em liberdade. Autoria e materialidade devidamente fundamentadas. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar o dolo da mercancia da ré. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais. Manutenção da condenação. Dosimetria comporta reparo. Basilar deve retornar ao mínimo legal. Confissão reconhecida, contudo, sem reflexo na pena. Súmula 231 do C. STJ. Reconhecimento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor. Ré primária. Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução de metade. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500680-42.2019.8.26.0616; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recursos defensivo e ministerial. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Circunstâncias da prisão e quantidade de droga incompatíveis com a alegação de posse de drogas para consumo pessoal. Condenação confirmada. Dosimetria. Pena imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo corretamente mantida no piso. Pena-base relativa ao crime de tráfico fixada acima do mínimo legal. Quantidade da droga que deve ser considerada para aferição do redutor. Redução de rigor. Apelante primário, preso com quantidade de drogas não excessiva, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Circunstâncias favoráveis. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau intermediário, em face da quantidade e variedade das drogas, com fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Pretensão da concessão do direito de recorrer em liberdade prejudicada. Recurso ministerial improvido e recurso da Defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500411-86.2020.8.26.0286; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Ainda, no que diz respeito ao fator de redução, não há violação ao princípio do bis in idem, quando este subscritor utilizou-se da mesma regra – quantidade e natureza da droga – para dosar a redução em ½ (metade), haja vista ter se utilizado da

mesma fundamentação em finalidades e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico -Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha - Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n. 11.343/06 Ainda que as investigações tenham se iniciado em razão de meras denúncias anônimas, a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como pelo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, será de rigor, sempre que o conjunto probatório, alicerçado em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 do referido diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Quantidade e variedade de substância tóxica apreendida indicativa de maior potencial nocivo da conduta do agente - Circunstância objetiva que deve pesar tanto para majorar a pena-base como para simultaneamente justificar aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em percentual abaixo do máximo - Inexistência de bis in idem O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a natureza e a quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a conduta social do agente. A incidência do primeiro fator mencionado, de ordem qualitativa e quantitativa, não só pode - como deve - ocorrer, tanto na primeira fase do cálculo da pena, como também cumulativamente na terceira, na qual será fixado o percentual de eventual redução, na hipótese de estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Assim, ainda que a pena-base já tenha sido majorada com lastro na quantidade e na variedade do tóxico apreendido, poderá perfeitamente o Magistrado, com base no mesmo fundamento, deixar de aplicar o redutor em seu máximo, e estabelece-lo em patamar mínimo ou intermediário, sem que tal proceder implique em bis in idem; isso porque referido elemento qualitativo e quantitativo será necessariamente apreciado em cada fase do cálculo sob perspectivas completamente distintas. Na primeira fase, a quantidade e a variedade da substância apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da intensidade de lesão à saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do grau de envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa. (TJSP; Apelação Criminal 0012004-89.2018.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Atento a primariedade do acusado, além da quantidade de pena imposta, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVADEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Vinicius dos Santos Siqueira, qualificado nos autos na fl. 24, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, razão pela

qual o CONDENADO ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos; pelos fundamentos acima, ABSOLVO Vanderlei dos Santos Siqueira da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Preenchendo o acusado Vinicius os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa. Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuarão a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União. Deixo de determinar o lançamento do nome do réu Vinicius no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu Vinicius ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, o mesmo acontecendo com o acusado Vanderlei.

P . I . C .

São Paulo, 23 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.